

1500412-63.2022.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim - SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500412-63.2022.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500412-63.2022.8.26.0363

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia e seu aditamento (fls. 90/91), nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, nas imediações da Praça dos Direitos Humanos e do Centro Dia do Idoso, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, consistentes em 20 porções de cocaína, com peso aproximado de 17,5 g, e 01 pedra de crack, com peso aproximado de 0,2g.

Recebida a denúncia, em 24 de março de 2022 (fls. 67/68), e o seu aditamento (fls. 92), o réu foi citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação (fls. 73/74).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 123).

Convertidos os debates em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia, opinando pela fixação de pena acima do mínimo legal, em razão da nocividade da droga, e de regime inicial fechado, sem a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, além da aplicação da agravante da reincidência e da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06 (fls. 122).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do réu, sustentando a tese de insuficiência do conjunto probatório para demonstração da autoria do delito (fls. 122).

É o relatório

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 08) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 80 e 83), que resultaram positivos para cocaína.

Vejamos.

Ao ser interrogado, em juízo, o acusado negou a prática do crime declarando que o entorpecente pertencia ao indivíduo que se evadiu do local em uma bicicleta. Disse ainda que não o conhecia e que se encontrava ali apenas para participar de um churrasco com um amigo.

Como veremos a seguir, a versão apresentada pelo réu não encontrou respaldo nas provas apresentadas pelas partes.

Os guardas municipais Carlos Alberto de Oliveira Campos e Eduardo Gabrelon relataram que faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática intensa de tráfico, quando foram informados por um transeunte de que dois indivíduos estavam fazendo churrasco e vendendo drogas. Prosseguiram, afirmando que se dirigiram para o local indicado pelo informante e que visualizaram o réu entregando um tubo de cor preta para um indivíduo que conduzia uma bicicleta. Este último, segundo os depoentes, evadiu-se do local, jogando o tubo preto ao solo durante a fuga, ao passo que o acusado resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo. Encerraram, informando que dentro do tubo preto foram encontrados 20 pinos de cocaína e um papelote de crack (fls. 02/03 e 122).

Os guardas municipais chegaram até o réu após serem informados por transeuntes de que dois indivíduos estavam praticando tráfico ilegal de drogas no local do crime e lograram apreender vinte porções de cocaína e uma porção de crack que estavam acondicionadas no interior de um tubo preto dispensado pelo comparsa do réu durante a sua fuga.

O réu declarou que estava fazendo um churrasco com um amigo no local onde foi detido, mas não arrolou este último como testemunha, nem apresentou outra prova a respeito dessa alegação, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do CPP. Assim, não há como se acolher a pretensão absolutória da defesa, pois a natureza e a quantidade da droga apreendida, a forma de sua embalagem e as circunstâncias em que se deu a prisão do réu permitem que se afirme com segurança que ele estava praticando o comércio ilícito de drogas.

Nesse sentido:

"Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273.

Ademais, a versão apresentada pelos guardas municipais é digna de plena credibilidade, pois, além de eles haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há qualquer evidência de que faltaram com a verdade para prejudicar o réu ou para legitimar as suas ações.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado: "os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos hão de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais. Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente de polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isso mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que a do cidadão comum." (in "Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, VOL. 8, pág. 386).

Oportuno lembrar que, por estar previsto em um tipo misto alternativo, o crime de tráfico ilegal de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) pode ser configurado pela prática de qualquer um dos verbos descritos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar.

Além disso, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a quantidade de porções encontradas pelos guardas municipais não se demonstra compatível com a posse para mero consumo e com a situação financeira do réu.

Por outro lado, não obstante a natureza objetiva da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, essa não deve incidir no caso em tela, pois o crime de tráfico não estava sendo praticado nas dependências ou nas imediações dos locais descritos no aditamento da denúncia.

Preleciona Vicente Greco: "O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a Lei procura coibir: as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem" (Lei de Drogas Anotada - Lei 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 145).

Analisando o levantamento do local segundo o critério desse eminente processualista, verifica-se claramente que a praça e a instituição não estão situadas nas imediações do local do crime. Apesar de a distância linear de ambas ser inferior a 300 metros (a da primeira é 281 metros e da segunda, 275 metros), a distância real é muito superior, porque não há acesso direto entre o local do crime e esses sítios, sendo necessário, para chegar até eles, percorrer um trajeto irregular, que contorna diversas ruas paralelas e transversais.

Nas imediações do local do crime há apenas uma igreja, mas já está assentado na doutrina e na jurisprudência que templos religiosos não foram elencados no rol do inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a sua absolvição, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 2. Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam

partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão. 3. Não há como ser reconhecida a incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos acusados possuidores de maus antecedentes. 4. As peculiaridades do caso concreto (maus antecedentes, quantidade e natureza da droga, bem como circunstâncias em que praticado o delito) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 5. Ordem parcialmente concedida, para afastar a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda da paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta.

Verifico que ele possui maus antecedentes, em virtude de ostentar uma condenação definitiva que gera reincidência, porém essa será considerada como agravante da pena, para que não haja bis in idem (fls. 30). Nada há de relevante quanto às demais circunstâncias, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Da mesma forma, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. A quantidade e a natureza da droga apreendida tampouco autorizam a exasperação da pena, nos termos do o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Assim, com fulcro no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em virtude da reincidência gerada pela condenação definitiva no processo nº 1501093-04.2020.8.26.0363, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/08/2021 (fls. 30/31), majoro a pena de 1/6 (um sexto), para que atinja 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, montante em que a torno definitiva, ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas capazes de influir em seu cômputo.

Consigno, por fim, o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, por ser reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, para condená-lo ao cumprimento de uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Apesar de reconhecida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade dos artigos 33, § 4o, e 44 da Lei 11.343/06, no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade, bem como de conceder sursis, por não estarem preenchidos os requisitos legais e por entender que tal medida é insuficiente como forma de punição, principalmente em razão de sua reincidência específica.

Com fulcro no § 1o do artigo 2º da Lei 8.072/90, diante da pena aplicada e da reincidência, fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista que permanecem vigentes as condições que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, principalmente a necessidade de garantia da ordem pública pela periculosidade demonstrada por ele e pelo risco de reiteração criminosa, deixo de lhe conceder o direito de apelar em liberdade. Recomendem-no na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, nome no rol dos culpados.

Ao defensor nomeado arbitro honorários advocatícios, no valor correspondente a 70% da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Mogi Mirim, 22 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA